

연차 휴가의 법적 성격과 쟁점

박수근* · 김근주**

目次

- I. 문제의 소재
- II. 연차휴가의 법적 성격에 관한 비교법적 검토
- III. 연차휴가의 발생요건의 해석론
- IV. 연차휴가의 발생요건과 취업규칙의 효력
- V. 연차휴가 산정과 쟁의행위
- VI. 결론을 대신하며

I. 문제의 소재

「근로기준법」(이하 근기법) 제60조 제1항은 “사용자는 1년간 8할 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다”고 규정하고 있다.¹⁾ 이 때 ‘8할 이상의 출근’이란 역법상의 1년 중 8할을 의미하는 것이 아니라 출근해야 하는 소정근로일을 전제로 한다. 그러므로 근로자가 연차휴가 청구권을 취득하기 위해서는 “1년간의 소정근로일수 중 8할 이상의 출근

* 朴秀根 : 한양대학교 교수(sekeun@hanyang.ac.kr)

** 金根住 : 한양대학교 박사과정(bridkim@paran.com)

1) 참고로 월차와 연차휴가제도를 규율하던 개정전 근기법 제59조는 사용자는 1년간 개근한 근로자에게는 10일, 9할 이상 출근한 자에 대하여는 8일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하였다.

일”이라는 요건을 충족해야 한다. 그러나 근기법은 출근과 관련하여 “업무상 재해와 질병, 임신 중인 여성근로자가 근기법 규정에 따라 휴업한 기간(동조 제6항)”만을 규정할 뿐 다른 상황에 대해서는 기준과 해석에 관하여 명확하게 규정하고 있지 않다.

최근 이와 관련하여 크게 두 가지 사항이 문제점으로 제기되었다. 첫째, 취업규칙에 연차휴가의 요건을 규정한 경우 그 효력 문제이다. 취업규칙에서 연차휴가의 발생요건과 관련하여 ‘정직 또는 직위해제, 휴직 등이 없는 경우가 개근’이라고 규정하고, 이에 따라 정직 내지 직위해제 기간을 소정 근로일수에 포함시키면서 결근으로 처리한 경우에, 해당 근로자의 연차휴가 발생일수에 영향을 미친 이 취업규칙의 효력이 인정되는가 하는 점이다. 둘째, 연차휴가 산정시 쟁의행위기간을 어떻게 취급할 것인가의 문제이다. 근로자가 장기간 파업에 참가하여 근로제공을 위해 출근한 날이 많지 않은 경우에는 소정근로일 및 출근을 어떻게 보는가에 따라서 연차휴가 발생 유무 및 범위에서 차이가 난다.

이하에서는 동법 제60조에서 규정한 연차휴가의 취지 및 법적 성격을 비교법적으로 검토한 후, 상기한 문제점을 해결하기 위한 현행 근기법의 합리적이고 타당한 해석방법을 해석론과 개별 사례를 통해 검토하고자 한다.

II. 연차휴가의 법적 성격에 관한 비교법적 검토

연차휴가의 산정기준의 문제는 해석상의 문제로 연차휴가의 법적 성격과 직접적인 연관성을 갖는 것은 아니다. 그러나 구체적인 사례들에서 문제가 되는 근본적인 원인은 연차휴가를 어떠한 성격으로 볼 것인지, 즉 보상적 성격으로 볼 것인지 아니면 보상적 성격으로 파악할 것인지와 상당한 연관성이 있다. 그러므로 이하에서는 현행 근기법상 연차휴가의 법적 성격을 살펴보기 위하여 비교법적으로 검토하고자 한다.

1. 비교법적 검토

비교법적 검토의 대상으로는 보편적인 국제기준인 ILO 협약과, 국내법에 직접적인 영향을 미치지 않는 않지만 간접적인 비교 대상이 되는 EU 지침을 살펴보고, 개별국가 입법은 연차휴가제도가 정비되어 있는 독일, 1998년 근로시간법령으로 연차휴가제도를 입법화한 영국, 우리나라의 노동관계입법에 많은 영향을 미치고 있는 일본을 살펴본다. 이들 비교대상의 전반적인 입법 소개는 선행 연구들²⁾이 자세하게 하고 있으므로, 이하에서는 연차휴가의 의의 및 발생요건, 연차휴가기간 및 사용방법, 연차휴가수당으로의 대체 가능 여부 등을 중심으로 근기법의 연차휴가의 법적 성격을 확인하는데 중점을 두고자 한다.

(1) 국제기준

연차휴가에 관한 ILO의 기준으로는 1936년 제52호 협약과 1970년 제132호 협약이 있다. 이 중 제132호 협약의 내용을 살펴보면, 우선 연차휴가의 의의 및 발생요건에 관하여, 선원을 제외한 모든 근로자는 1년의 근무기간에 대하여 3주 이상의 휴가를 부여하여야 한다고 규정하고(제3조 제3항), 근무기간이 1년이 되지 못하는 근로자는 그 근무기간에 비례하는 유급휴가를 받을 권리를 가진다고 규정하고 있다(제4조). 동협약은 “공휴일 및 관습상의 휴일”은 연차휴가 일수에 포함시키는 것을 금지하고 있으므로 3주는 역법상 21일이 아닌 출근의무일 기준 21일을 의미하는 듯하다. 연차휴가기간은 순수한 휴가적 목적으로 사용되어야 하며 “질병 또는 상해로 인한 근로불능”기간을 연차휴가기간으로 포함시키는 것은 금지된다(제5조 제4항). 연차휴가를 별도로 최저근무일수 이상을 근로한 자에게만 부여하는 것을 허용하고 있는데, 각국의 관련 유권기관은 최저근무일수를 6개월

2) 이에 관한 선행연구로는 이철수, “휴일·휴가제도에 관한 비교법적 연구”, 「노동법학」(제9호), 한국노동법학회, 1999; 김재훈, “연차유급휴가제도의 개편에 관한 연구”, 「노동법학」(제13호), 한국노동법학회, 2001 등 참조.

을 초과하여 설정하여서는 안된다고 규정하고 있다(제7조). 연차휴가는 일정한 조건하에서 분할이 인정되지만, 적어도 중단없는 2주로 구성되도록 하고 있다(제8조). 연차휴가수당에 관해서는 별도의 규정 없이 고용이 종료되는 때에 발생한 유급휴가 또는 이에 상당하는 보상을 받는다고 정하고 있는데(제11조), 보상을 받기 위하여 또는 다른 이유에서 최저 연차휴가를 받을 권리를 포기하거나 그 휴가를 폐지하는 협정은 무효라고 규정하고 있는 점(제12조)을 고려할 때, 휴가에 갈음하는 보상은 고용종료시에만 한정되어 있는 듯하다.³⁾

한편 유럽연합(EU)의 전신인 유럽공동체(EC)는 영국의 반대에도 불구하고 1993년 11월 23일 “근로시간편성에 관한 지침”을 채택하였는데, 이 지침에서는 근속기간 1년에 최소한 4주(1999년 11월 이전까지는 3주)의 유급휴가를 부여하도록 규정하고 있고(제1조), 최저 연차휴가 기간은 고용관계가 종결된 경우를 제외하고는 수당으로 대체될 수 없다고 규정하고 있다(제2조). 이 지침은 2000년 7월 22일 개정되었는데, 연차휴가에 대한 내용은 변경이 없었다.

이러한 국제기준은 연차휴가의 발생요건에 대하여 근속기간만을 규정하고 있다는 점과 연차휴가수당을 고용종료의 경우와 같이 제한적으로만 인정하고 있다는 점이 우리나라의 입법과 비교하여 가장 큰 특색이라고 할 수 있다.

(2) 독일

독일은 연방휴가법(Bundesurlaubsgesetz, BUrlaG) 제2조 내지 제13조에 서 연차휴가의 발생요건, 기간 및 연차휴가수당에 대하여 규정하고 있다. 근로관계의 존속기간이 6개월이 경과한 근로자에 대하여 18일의 연차휴가가 발생한다. 이 때 6개월 근로관계 존속기간은 신규취업자가 일정한 근속기간 없이 동일한 연차휴가를 받는 것을 방지하기 위한 규정이며, 6개월전

3) 김재훈, 앞의 글, 214면.

근로관계가 종료된 근로자는 각 월별로 총 연차휴가의 1/12의 휴가청구권이 발생한다(동법 제5조 제1항 참조).⁴⁾ 휴가청구권은 현실적인 근로제공을 기준으로 하는 것이 아니라 단순한 근로관계의 존속을 기준으로 발생하므로, 예컨대 병가가 1년간 지속된 근로자에게도 휴가권이 발생하게 된다.⁵⁾

휴가는 최소한 공휴일을 제외한 12일이 연속하여 부여되어야 하고(제7조 제2항), 부분적인 휴가청구권은 예외적인 경우로 한정된다. 연차휴가를 금전으로 보상하는 행위는 연방휴가법의 목적에 반하는 것으로 허용되지 않으며, 예외적으로 근로관계의 종료로 인하여 발생한 휴가청구권을 실현시킬 수 없는 경우에만 가능하다(동법 제7조 제4항).

(3) 영국

1998년 근로시간과 최저임금에 관한 입법을 하기 전까지 이에 관한 일반적인 법령이 없었기 때문에 연차휴가에 관해서는 단체협약에 정한 바에 따랐다. 그러나 EU지침의 준수의무에 따라서 ILO(제132호 협약) 및 EU지침(근로시간 편성에 관한 지침)을 고려한 근로시간 및 최저임금에 관한 법령을 제정하여야 했다. 이에 따라 근로시간법령(The Working Time Regulations 1998)이 제정되었다.

1998년 근로시간법령은 연차휴가에 관하여 제13조에서 제16조까지 규정되어 있다. 이를 살펴보면, 연차휴가는 근로자의 권리로 4주 이상 부여되어야 하며(제13조 제1항), 3년의 계속근로에 대하여 1일의 가산을 인정하고(제13조 제2항) 13주의 계속근로기간을 충족하는 근로자에게 부여된다(제13조 제7항). 원칙적으로 연차휴가를 다 사용하지 못한 경우에는 이월되며 금전으로 보상은 불가능하지만, 고용종료 등 예외적인 경우에 한하여 금전보상이 가능하다(제14조). 또한 근로자는 휴가일을 선택할 수 있지만

4) 연차휴가의 발생요건은 근로관계가 존재하는 사실이 중요하므로, 이 요건에만 해당되면 사용자는 연차휴가를 인정해야 한다는 점에서 보장적 성격으로 파악할 수 있다.

5) 김재훈, 앞의 글, 216면.

(제15조 제1항), 최종적인 휴가일은 사용자와의 협의에 의하여야 하며(제15조 제2항), 이 때 사용자는 다른 요소들을 고려하지 않고 이미 신청한 근로자의 휴가와 조화를 이루는 한도에서 휴가일을 조정할 수 있다(제15조 제3항 이하). 휴가기간동안의 임금에 관해서는 1996년 고용권법의 임금산정방법에 따른 임금을 적용한다(제16조).

그러나 이에 대하여 유럽사법재판소는 13주의 계속근로기간을 충족하는 근로자에게만 연차휴가를 부여하고 그 이하의 기간을 근로한 자에 대해서는 비례적인 부여를 규정하고 있지 않은 근로시간법령이 유럽연합지침에 부합되지 않는다고 판시하였고,⁶⁾ 이에 따라 근로시간법령의 연차휴가 부여 기준기간을 삭제하였다. 2009년 4월을 기준으로 모든 근로자는 1년의 근로에 대하여 최저 연차휴가가 5.6주가 보장되며(제13조A), 이는 근로시작과 동시에 보장된다는 점을 확인하였다(제15조A). 이와 더불어 계속근로에 대한 가산이 연차휴가의 보장적 성격과 부합되지 않는다는 유럽사법재판소의 판단에 따라 이를 삭제하였다.⁷⁾

(4) 일본

연차휴가의 발생요건에 관해 노동기준법 제39조에서는 ‘고용일로부터 기산하여 6개월 이상 계속 근무하고 전체 근로일의 8할 이상 출근한 근로자에 대하여’ 10일의 휴가를 부여하여야 한다⁸⁾고 규정하고 있는데(동조 제1항), 기본적으로 근로일(소정근로 의무 발생일)과 출근을 요건으로 하여 발생하고 있는 점, 업무상 질병 등의 경우 출근한 것으로 간주하는 등의 내용을 고려할 때 근거법 규정과 구조상 매우 유사하다.

동조 제2항에서는 제1항의 연차휴가에 대하여 계속근로연수에 따라 다음과 같이 추가적인 연차휴가가 발생함을 규정하고 있어 앞서 살펴본 독

6) [2001] ECR I-04481 사건. 이에 관한 내용은 Hugh Collins, K. D. Ewing, Aileen Mccolgan, Labour Law-Text and Materials, Oxford and Portland, Oregon, 2005, 408면 참조.

7) Hugh Collins, K. D. Ewing, Aileen Mccolgan, 410면 참조.

일과 영국의 입법과는 다르게, 근속연수와 연차휴가를 연계하고 있는데, 근속기간 6개월을 충족한 근로자는 다음날에 10일의 연차휴가청구권이 발생하고, 20일을 상한으로 근속연수 1년에 대하여 <표 1>의 연차휴가일수가 가산된다.

<표 1> 일본의 근속연수와 추가적 연차휴가

6개월 경과일부터 기산한 계속근로연수	가산되는 휴가일
1년	1일
2년	2일
3년	3일
4년	4일
5년	5일
6년 이상	6일

연차휴가의 발생요건에 관한 “전체 근로일”은 “근로자에게 근로계약상 근로의무가 부과되고 있는 날”을 말하는데, 이와 관련하여 주로 논의되는 내용은 사용자에게 책임사유가 있는 휴업일과 양당사자에게 책임없는 휴업일을 근로일로 포함시킬 것인지 여부이다. 이에 대해서는 학설의 대립이 있고, 판례는 사안에 따라서 조금 다르게 판단하고 있는 듯하다.⁸⁾

해당연도에 사용하지 못한 연차휴가에 대하여 금전보상 및 이월에 관한 별도의 규정은 없다. 이에 대하여 연차휴가가 해당연도에 법정 일수만큼 현실적으로 쉰다는 것을 보장하는 것이므로 노동기준법상 2년간의 시효규정에 따라 이월이 인정된다(동법 제115조). 또한 연차휴가에 대한 금전적 보상을 합의한 후, 발생된 연차휴가 취득을 인정하지 않는 것은 연차휴가 규정에 반하지만, 결과적으로 사용하지 못한 연차휴가일수에 따라 수당을 지급하는 것은 위법이 아니다.⁹⁾

8) 菅野和夫(이정 譯), 「일본노동법」, 법문사, 2007년, 300면 참조.

9) 菅野和夫(이정 譯), 위의 책, 310면 참조.

(5) 우리나라 법제와의 비교

ILO 또는 EU의 지침 등 국제기준을 수용하는 방식은 나라마다 다양하므로 일률적으로 적용된다고 할 수 없지만,¹⁰⁾ 해당 제도의 법적 성격을 파악하는데 있어서 고려해야 할 필요가 있다. 또한 비교대상 국가들도 각 국가별로 노동현실에 차이가 있으므로 근기법상 연차휴가에 대한 해석론에 직접적인 자료가 되지는 않지만, 법적 성격을 파악하는데 있어서 참고자료가 될 수는 있을 것이다. 현행 근기법 제60조는 2003. 9. 15. 일부개정시 도입된 것인데, 개정 이유에 대하여 “근로시간 및 휴가제도를 국제기준에 맞추어 개선하려는 것”이라고 하면서 “국제적인 입법례에 따라 월차유급휴가를 폐지하고, 여성인 근로자에 대하여 월 1일의 유급생리휴가를 주도록 하던 것을 무급화하여 사용자의 부담을 경감”하도록 한 것이라고 설명하고 있는데,¹¹⁾ 앞서 보았듯이, 국제기준 및 다른 국가의 입법과 우리나라 입법을 비교하면 일정한 차이가 있다.

연차휴가의 발생요건에 관하여, 국제기준 및 독일과 영국은 일정기간 이상의 근속연수만을 연차휴가의 발생요건으로 규정하고 있는데, 이는 일본의 입법과 우리나라의 근기법이 일정한 출근을 전제로 하는 것과 차이가 있다.

최소연차휴가기간에 대하여 국제기준 및 독일과 영국은 비교적 장기의 기간을 규정하고 있는 것과 달리 일본(10일부터)과 우리나라(15일부터)는 상대적으로 휴가기간이 적다는 점에 차이가 있다.

연차휴가수당에 관해서는 국제기준 및 독일과 영국은 “고용종료의 경우”를 제외하고는 이를 인정하지 않고 있음에 반하여 일본은 “결과적으로 사용하지 못한 연차휴가에 대한 수당”을 지급하는 것을 인정하고 있다. 일본은 해석적으로 사용하지 못한 연차휴가에 대하여 2년의 시효를 적용하는 조건으로 이월을 인정하고 있다. 우리나라는 근기법 제61조(연차유급휴가

10) 협약을 비준하지 않은 경우에는 국제 입법을 수용할 의무가 없으므로, 이 경우에는 각국의 사정에 맞추어 참고하였다고 보아야 할 것이다.

11) 국가법령센터(<http://www.law.go.kr/main.html>)의 개정이유 참조.

의 사용 촉진)에서 이에 관하여 별도로 규정하고 있다. 또한 우리나라와 일본이 근속연수에 따라 연차휴가의 가산을 규정하고 있는 반면, 국제기준과 독일·영국은 이를 인정하고 있지 않다. 특히 유럽사법재판소는¹²⁾ 영국의 근로시간법령이 근속연수에 따라 연차휴가를 가산하도록 한 규정에 대하여 연차휴가의 보장적 성격과 부합되지 않는다고 판시하였고 영국은 이 규정을 삭제하였다.

2. 현행 연차휴가의 법적 성격

비교법적 검토를 통해 살펴본 것 같이, 현행 근기법은 일본의 입법과 유사하다. 우리나라와 일본은 연차휴가의 자격에 대하여 “일정한 출근”을 조건으로 인정하고 있으므로, 연차휴가를 전적으로 보장적 성격으로 볼 수는 없다. 그러나 연차휴가제도가 전적으로 보상적 성격만을 갖는 것으로 보는 것도 타당하지 않다. 헌법재판소는 “근로기준법상의 연차유급휴가는 근로자에 대하여 휴일 외에 매년 일정 일수의 휴가를 유급으로 보장하는 제도로서, 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제함으로써 근로자의 정신적·육체적 휴양을 통하여 문화적 생활의 향상을 기하려는 데 그 취지가 있다” 판시하여 그 성격을 근로자에게 보장되는 근로의 권리¹³⁾로 보면서 “근로자들의 생리적인 회복을 위한 휴게시간이나 주휴일과는 달리 연차유급휴가는 임금 삭감 없이 휴가기간을 스스로 결정할 수 있게 함으로써 근로자들이 노동으로부터 일정기간 해방되고 사회적·문화적 시민생활을 영위할 수 있는 기회를 보장하기 위한 것으로 본래적 의미에서의 '여가'를 보

12) 앞의 [2001] ECR I-04481 사건.

13) 헌법재판소는 “근로의 권리란 인간이 자신의 의사와 능력에 따라 근로관계를 형성하고, 타인의 방해를 받음이 없이 근로관계를 계속 유지하며, 근로의 기회를 얻지 못한 경우에는 국가에 대하여 근로의 기회를 제공하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리를 말하는 바, 이러한 근로의 권리는 생활의 기본적인 수요를 충족시킬 수 있는 생활수단을 확보해 주고 나아가 인격의 자유로운 발현과 인간의 존엄성을 보장해 주는 기본권”으로 보고 있다(헌재 1991. 7. 22. 89헌가106 ; 헌재 2002. 11. 28. 2001헌바50 참조).

장한 것”으로 보고 있다.¹⁴⁾

이와 같이 헌법재판소는 연차휴가가 생리적인 회복이 목적이 아닌 문화적 생활의 향상을 목적으로 하고 있다는 점, 휴가기간을 스스로 결정하여 본래적 의미에서의 여가를 보장하고 있다는 점, 인간의 존엄성에 바탕을 둔 근로의 권리라는 점을 인정하고 있다. 또한 근기법상 근로자에게 휴가 청구권을 인정하고 있고(제60조 제5항), 이에 대한 예외를 “사업운영에 막대한 지장이 있는 경우” 또는 근로자대표와의 서면합의에 따른 특정(제62조)과 같이 엄격하게 제한하고 있는 점을 고려한다면, 적어도 연차휴가의 보장적 성격이 전적으로 배제될 수는 없을 것이다. 결론적으로 현행 근기법상 연차휴가제도는 보장적 성격과 보상적 성격이 동시에 존재하고 있다고 볼 수 있다.

III. 연차휴가의 발생요건의 해석론

1. 근기법상 규정과 해석론

사용자는 1년간 8할 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다(근기법 60조 1항). 법문은 1년간의(기준기간) 8할 이상 출근(발생요건)한 근로자에 대하여 15일의 유급휴가를 부여한다고 규정하고 있어, 연차휴가의 발생요건으로 “8할 이상의 출근”을 규정하고 있다.

기준기간인 “1년”은 역법상은 365일을 의미하는 것이 아니라 “근로자에게 근로계약상 근로의무가 부과되고 있는 날”인 소정근로일수를 말한다고 보는 입장이 있다. 이에 따르면, 연차휴가의 산정은 “출근 / 소정근로일”이라는 산정방식을 통해 8할 이상 이상이 되는 경우에 부여된다.¹⁵⁾

¹⁴⁾ 헌재 2007. 8. 30. 2004헌마670.

¹⁵⁾ 권영국, “근로자의 정직 또는 직위해제와 연차유급휴가에 관한 취업규칙의 효력”, 『노동판례비평』, 민주화사회를 위한 변호사모임, 2008, 151면.

소정근로일이란 법령의 범위 내에서 근로자와 사용자가 사전에 근로하기로 정한 날, 즉 근로자가 근로계약에 의하여 출근여야 할 의무를 부담하는 날을 말한다. 보통 근로자와 사용자는 출근의무에 관하여 출근의무가 없는 날을 정하기 때문에 계산상 “1년(365일) - 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날”을 뺀 나머지 일수를 소정근로일로 본다. 그러나 사전에 출근의무가 없는 날을 정하지 않더라도 취업규칙 또는 단체협약 등에서 당초 근로하기로 정하였으나 근로자 또는 사용자가 사전에 예측할 수 없는 특별한 사유가 발생하여 '근로의무가 정지되는 기간'은 소정근로일에서 제외된다.¹⁶⁾ 한편 출근한 날은 결근하지 아니하고 실제로 근무한 날을 말한다. 따라서 원칙적으로 소정근로일수에서 결근일수를 공제한 날을 출근일수로 한다.¹⁷⁾ 이와 같은 산정방식을 도표로 나타내면 다음과 같다.

<표 2> 연차휴가 산정방식

출근한 날 = 소정근로일 - 결근한 날
소정근로일 = 365일 - (법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날)

“근로의무가 정지되는 기간”으로 볼 수 있는 기간의 유형은 다양하겠지만, 그 중에서도 근기법 제60조에서 규정하고 있는 “업무상 재해로 인한 휴업기간, 산전후휴가(동조 제6항)는 출근한 것으로 본다”고 규정하고 있다. 또한 “사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권 기타 공민권의 행사 또는 공의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하는 경우에는 거부하지 못한다(근기법 제9조)”는 취지를 고려할 때 공민권행사와 관련된 기간¹⁸⁾은 출근한 것으로 보아야 할 것이다. 그 밖의 쟁의행위기간, 휴직기

16) 권영국, 앞의 글, 152 - 153면.

17) 권영국, 앞의 글, 155면.

18) 예비군훈련기간(향토예비군설치법 제10조), 민방위훈련 또는 동원기간(민방위기본

간, 정직·대기발령과 같이 사용자의 처분으로 인한 근로의무 면제기간 등을 어떻게 취급할지에 관해서는, 위 산정방식에 따르면 동기간의 “근로(제공)의무”의 유무를 통해서 해결하여야 할 것이다.

2. 근로(제공)의무와 소정근로기간

(1) 근로제공의무의 성격

근로의무 또는 근로제공의무는 근로자의 근로계약상 주된 의무로 사용자의 임금지급 의무에 상응하는 것이다. 근로자는 사용자에게 자신의 근로를 대신하여 제3자의 노동력을 제공하는 것은 허용되지 않는다. 근로제공의무는 근로의 내용·장소·수행방법에 관하여 구체적인 약정을 통하여 확정되는 것이 아니라, 근로의무를 부담하는 때에 사용자의 지휘명령에 따르기로 약정하면 된다. 요컨대 근로제공 의무는 근로자가 노동력을 사용자의 처분에 맡기고 근로의 내용·장소·수행방법 등에 관한 사용자의 구체적인 지휘명령에 따른 근로를 제공할 의무를 말한다.¹⁹⁾

또한 근로제공 의무는 구체적인 근로를 제공할 의무를 말하는 것이 아니라 자신의 노동력을 사용자가 처분할 수 있는 상태에 두는 것을 의미하므로 사용자가 실제로 이를 처분하지 않은 경우에도 근로제공 의무를 이행한 것이 된다.²⁰⁾ 이에 대하여 사용자는 근로자의 근로의무에 대한 대가로서 임금을 지급할 의무를 진다. 임금은 제공된 근로에 대한 반대급부이므로, 근로자가 실질적인 근로제공을 하지 않은 경우에는 임금지급 의무가 발생하지 않는다. 그러나 근로자가 근로제공을 하였음에도 불구하고 근로

법 제23조), 공민권행사를 위한 휴무일(공직선거법 제6조 제2항) 등에서는 이에 관하여 별도의 규정을 두고 있는데, 예컨대 향토예비군설치법 10조는 “타인을 사용하는 자는 그가 고용하는 자가 예비군대원으로 동원되거나 훈련을 받는 때에는 그 기간을 휴무로 하거나 그 동원이나 훈련을 이유로 불이익한 처우를 하여서는 아니된다”고 규정하고 있다.

19) 임종률, 노동법(8판), 박영사, 2009, 333면 이하 참조.

20) 임종률, 위의 책, 334면.

제공의 수령을 거부하거나 부당해고 등 사용자의 책임 있는 사유로 인하여 근로자가 근로제공을 할 수 없었던 경우에는 임금을 지급하여야 한다. 이러한 점들을 고려할 때 근로자의 근로의무는 근로를 제공할 상태에 두는지, 이에 대하여 사용자는 지휘명령권 행사의 기대가능성이 있는지 그리고 대가로 임금이 지급되었는지 여부를 통하여 확정할 수 있을 것이다.

(2) 근로제공의무를 통한 판단의 한계

이처럼 소정근로기간을 근로의무 유무를 기준으로 판단할 때, 위에서 문제가 되는 기간, 즉 쟁의행위기간, 휴직기간, 정직·대기발령 등 사용자의 처분으로 인한 기간은, 근로의무와 대가관계에 있는 사용자의 임금지급 의무를 고려한다면, 소정근로일에서 제외된다고 보는 것이 타당할 것이다.

그러나 사용자의 주된 의무인 “임금지급 의무”만으로 판단한다면 위법한 쟁의행위기간, 무급휴직기간 등의 취급을 어떻게 할 것인지가 문제가 된다. 이와 함께 휴직 및 정직의 경우에서, 임금지급의무를 중심으로 판단한다면 휴직 및 정직의 원인을 고려하지 않게 되는데, 이러한 방식이 타당한지 의문이 제기될 수 있다. 한편, 근로제공의무의 존부만으로 판단한다면, 1년에 걸쳐 “문제기간”이 발생하는 경우에는 출근율 산정을 어떻게 하여야 할 것인가라는 문제도 제기될 수 있다.²¹⁾ 이는 “장기의 휴직”과 같은 경우에 발생할 수 있으며, 근로자의 근로제공의무 및 사용자의 임금지급의무와 관계없이 산정 대상기간이 존재하지 않으므로 산정이 불가능하기 때문에 새로운 해결방법이 필요하다. 이와 함께 흔히 취업규칙에서 결근, 정직 등의 정의를 규정하면서, 근로의무의 존부를 취업규칙의 규정으로 확정하는 경우가 있는데, “소정근로일”을 근로자와 사용자가 사전에 근로하기로 정한 날이라고 할 때, 법령 및 단체협약과 별도로 취업규칙에 정한 날을 “근로자와 사용자가” 정한 날로 볼 수 있는지(취업규칙의 효력) 역시 고려해야 할 것이다.

21) 임종률, 앞의 책, 440면.

이러한 문제점들은 연차휴가 산정의 해석론을 바탕으로 하여 개별적으로 검토되어야 할 것이다. 이하에서는 우선 연차휴가의 발생요건과 관련한 취업규칙의 효력을 최근 제기된 사례를 통하여 살펴보고, 이어서 연차휴가 산정시 쟁의행위기간의 취급에 관하여 살펴보도록 한다.

IV. 연차휴가의 발생요건과 취업규칙의 효력

1. 사례와 판결

(1) 사실관계

회사는 근로자들이 불법파업을 한 사실을 징계사유로 하여 정직 내지 직위해제의 처분을 하였다. 2004년경 적용되던 취업규칙에는 “1년간 개근한 직원에게는 10일, 9할 이상 출근한 직원에게는 8일의 연차유급휴가²²⁾를 주며, 정직 또는 직위해제, 휴직(업무상 질병 또는 질병으로 인한 휴직은 제외) 등이 없는 경우가 개근”이라고 규정되어 있었다. 회사는 이에 근거하여 정직 내지 직위해제 기간을 결근으로 처리함으로써 해당 근로자들에게 연차휴가근로수당을 지급하지 아니하였다. 해당 근로자들은 정직 등 징계를 받게 되면 그 기간에는 근로제공의 의무가 부과되지 아니하므로 근로자가 임의로 출근하지 않은 날로 볼 수 없으므로 소정근로일수에서 제외하는 것이 타당함에도 불구하고, 회사의 취업규칙은 그와 다르게 규정하고 있어 근기법에 위반하는 것으로 무효이어서, 지급하지 아니한 연차휴가근로수당을 청구하였다. 특히, 징계기간은 근로자가 임의로 출근하지 않은 날로 볼 수 있는지를 노동부에 질의하여 자신들의 주장에 부합하는 회신서²³⁾를 받아 이를 근거로 제시하였다.

²²⁾ 이 내용은 월차와 연차의 유급휴가제도가 있던 개정전 근기법 제59조의 내용과 일치한다.

(2) 판결요지와 의문점

제1심, 2심 법원은 “징계를 받은 근로자는 사용자의 징계권이 부당하게 행사되었다고 판단하면 징계무효확인의 소를 포함한 다양한 권리구제절차가 있고, 징계를 당하여 근로를 제공하지 아니한 것은 자신의 귀책사유와 무관하게 근로를 제공하지 못한 것으로 볼 수 없는 점, 노동부의 질의회신은 법률상 효력을 발생시킬 수 없는 점, 일반 사업장과는 반드시 동일하다고 볼 수는 없으나 국가공무원 복무규정에서도 휴직, 정직, 직위해제의 기간은 재직기간에 산입하지 아니하고, 정직 및 직위해제기간은 연가일수에서도 공제하고 있는 점, 이 사건 취업규칙은 1994년 회사 소속 근로자 94%의 찬성으로 제정된 이래 5차례 개정 및 관계기관에 신고를 거치면서 회사의 근로자들로부터 아무런 이의제기 없이 유효하게 통용되어 온 점 등을 고려할 때, 취업규칙이 근기법에 정해진 기준보다 불리하게 규정되어 있다고 볼 수 없고, 이 사건 징계가 적법, 유효하게 이루어진 이상 회사가 결근으로 처리한 것은 부당하다고 볼 수 없다”라고 판단했다.

상고심²⁴⁾에서도 유사한 취지에서 근로자들의 상고를 기각하였다. 구 근기법 제59조는 연차유급휴가에서 “개근”이나 “9할 이상 출근한 자”에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않으나, 연차유급휴가는 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제함으로써 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하려는 것에 그 의의가 있다. 정직이나 직위해제 등의 징계를 받은 근로자는 징계기간 중 근로자의 신분을 보유하면서도 근로의무가 면제되므로, 사용자는 취업규칙에서 정직 또는 직위해제 기간을 소정 근로일수에 포함시키되 그 기간 중 근로의무가 면제되었다는 점을 참작하여 연차유급휴가 부여에 필요한 출근일수에는 포함되지 않는 것으로 규정

²³⁾ 노동부 2007. 10. 25. 임금근로시간정책팀-3228(연차유급휴가부여시 소정근로일수 및 출근여부 판단기준)에 따르면, 근로자가 근로를 제공할 수 있음에도 사용자의 징계권의 행사로 이루어진 「정직」 또는 「강제 휴직」 기간은 특별한 사유로 근로 제공 의무가 정지되는 날 또는 기간에 준하여 해석할 수 있는 기간으로 볼 수 있다고 하였다.

²⁴⁾ 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008다41666판결.

할 수도 있어, 취업규칙의 규정이 구 근기법에 반하여 근로자에게 불리한 것이라고 보기는 어렵다고 판시했다.²⁵⁾ 그러나 이러한 판례의 입장은 연차 휴가의 법적 성격을 별론으로 하더라도, 취업규칙에 대한 법적 효력이라는 관점에서 볼 때 이에 관한 검토가 필요하다.

2. 취업규칙의 규범적 특징

현행 근기법은 제93조 내지 제97조에서, 사용자에게 취업규칙의 작성, 취업규칙 신고의무, 필요적 기재사항과 함께 취업규칙의 작성과 변경시 근로자대표의 의견청취 및 불이익하게 변경할 경우 동의를 받도록 하고 있다. 또한 취업규칙의 내용이 감봉제재인 경우 최소한의 기준을 초과하지 못하도록 하고 있는 등 취업규칙의 내용이 해당 사업장에 적용되는 법령 또는 단체협약의 내용에 위반되지 않도록 하고, 취업규칙이 법령 또는 단체협약에서 정한 근로조건에 위반하는 경우 그 효력을 부정한다. 구체적으로 취업규칙의 내용 및 법적 효력은 취업규칙 대상이 근기법이 규율하고 있는 제도인지를 고려하여, 그 법적 성격에 따라서 다음과 같이 3가지로 구분될 수 있다.

첫째, 취업규칙에서 정한 내용이 근로조건이고 이에 대한 근기법의 내용이 강행적임과 동시에 해석론이 명확한 경우이다. 근기법 제50조의 근로시간 또는 제56조의 연장근로에 관한 가산임금 등에 위반되는 취업규칙의 내용은 그 자체에서 효력을 발생시킬 수 없고, 근기법 제96조는 이를 확인한 규정으로 이해할 수 있다. 둘째, 취업규칙에서 정한 내용이 근로조건에 관한 사항이며 강행적임에도 불구하고 그 범위와 내용이 분명하지 않거나

²⁵⁾ 이 판결의 영향으로 노동부는 전술한 바와 같은 종전의 행정해석을 변경하였다. 노동부(2009.09.01. 근로기준법-3296)의 ‘연차 유급 휴가 부여 기준과 소정 근로일 수 및 출근 여부’ 판단시 정직 기간 등 관련 행정해석의 변경에 따르면, 사용자가 징계권의 정당한 행사로 이루어진 「정직」 또는 「강제 휴직」 기간은 특별한 사유로 근로제공의무가 정지 되는 날 또는 기간에 준하여 해석할 수 있는 기간으로 볼 수 없다고 하였다.

법적 성격이 무엇인지에 관해 해석상으로도 의견이 대립할 수 있는 경우이다. 예컨대, 대상판결의 사안처럼, 근로자의 정직 또는 직위해제 기간을 소정근로일수에 포함시키되 연차유급휴가 부여에 필요한 출근일수에 포함되지 않는 것으로 취업규칙이 정한 경우이다. 이 때에는 해당 근기법 조문의 해석론에 취업규칙 규정이 부합되는지 여부를 통해 근기법 위반 여부가 판단될 것이다. 셋째, 근기법상 규율대상 또는 강행규정이 아니거나 근로조건 외 사항에 관해 취업규칙이 정하고 있는 경우이다. 이는 사용자의 재량의 범위 내에 있는 것으로 보아야 하며, 절차적 요건을 거쳤다면 취업규칙의 효력은 인정될 것이다.

3. 대상판결의 타당성과 법적효과

사용자는 취업규칙에서 소정근로일에 관한 사항을 규정할 수 있는데, 이는 근기법에서 명시적으로 규정한 근로조건이라고 볼 수는 없지만, 적어도 연차휴가라는 근로조건 발생요건이기 때문에 근기법상 규율대상이라고 보아야 한다. 이와 함께, 소정근로일이 “애초 사용자와 근로자가 근로하기로 한 날”이라 할 때, 사용자가 취업규칙으로 구체적인 기간의 소정근로일 포함 여부를 결정할 권한이 있다고 볼 수 없다. 앞에서 살펴보았듯이, 소정근로일은 “1년(365일) - 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날”이므로, 취업규칙은 대상기간이 근로의무가 없음을 규정할 수 있다는 점은 당연하지만, 반대로 대상기간이 근로의무가 있다는 점을 규정할 권한이 있다고 볼 수는 없기 때문이다. 그러므로 구체적인 소정근로일과 결근 및 출근의 의미에 관하여 취업규칙으로 정하였다 하더라도 근기법의 해석을 통해서 취업규칙의 합법성²⁶⁾이 판단되어야 할 것이다. 그러므로 취업규칙 규정이 유효하기 위해서는 근기법 제60조에서 규정한 연차휴

26) 합법성은 적법성을 포함하는 개념으로, 취업규칙이 명시적으로 근기법에 위반되는 경우에는 그 적법성이 문제되며, 취업규칙 규정이 근기법상 제도의 해석상 허용되지 않는 경우에는 동 규정 근기법에 부합되는지가 문제되는데, 이러한 판단을 합법성이라고 표현하였다.

가 산정기준을 해석한 후, 이를 통해서 취업규칙의 동 규정이 근기법에 위반되지 않는지를 판단하여야 할 것이다.

대상판결은, 명확하게 드러나지 않지만, 연차휴가제도의 법적 성격이 “근로 의무의 면제”에 있으며 징계기간동안도 “근로 의무가 면제”되므로 취업규칙의 효력이 근로자에게 불이익한 것은 아니라고 판단하고 있는 듯하다. 주장의 법리적 및 구체적 타당성을 추구하는 법원의 판단이라는 점을 별론으로 하더라도, 연차휴가 산정법은 근로조건에 관한 사항 또는 근로조건의 발생요건에 관한 사항이며 이는 강행적임에도 불구하고, 규정에 대한 해석론의 검토 없이 연차휴가제도의 법적 성격을 검토하여 취업규칙 규정의 합법성을 인정하는 방식은 방법론으로서 타당하지 않다. 만일 이러한 판례의 입장이 인정되기 위해서는 “근기법 제60조가 80%의 출근만을 규정하고 있으므로, 연차휴가의 기준은 ”출근을 하였는지 여부“가 되는데, 정직기간은 출근한 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라 출근한 것으로 보는 출근간주규정은 법령상 허용되는 경우만 인정된다”²⁷⁾ 등과 같은 해석론적 검토가 선행되어야 할 것이다.²⁸⁾

V. 연차휴가 산정과 쟁의 행위

헌법상 노동3권의 보장 법리에 비추어 볼 때, 쟁의행위에 참가한 근로자는 사용자에게 근로를 제공할 의무가 없고 이를 이유로 불이익을 줄 수

27) 종전의 행정해석 1987. 02. 05, 근기 01254-1774는 이와 유사한 근거를 들어서 정직 또는 출근정지 시 연차휴가 산정에서 결근으로 보았다.

28) 그러나 이러한 해석론도 제3장에서 살펴본 바와 같이 연차휴가 발생요건을 소정 근로일 / 출근한 날로 보고 ① 소정근로일 = 365일 - (법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날) ② 출근한 날 = 소정근로일 - 결근한 날로 파악한다면, 정직기간은 사용자에게 처분에 의하여 근로제공의무를 부담하지 않는 날임이므로 근로의무를 부담하는 소정근로일에 포함시킬 수 없으므로 타당하지 않다.

없는 것은 명확하다. 근로자가 파업에 참가하느라 근로를 제공하지 못한 경우 양 당사자의 “주된 의무”는 정지되므로 근로(제공)의무가 존재하지 않는다. 그러나 연차휴가 산정에 관하여 근기법이 일정한 요건을 규정하고 있으므로, 쟁의기간을 연차휴가산정에서 어떻게 취급할 것인지는 별도의 검토가 필요하다. 이 과정에서는 헌법상 권리의 행사와 연차휴가제도의 취지 역시 고려되어야 한다.

1. 연차휴가 산정시 쟁의기간에 관한 학설 검토

쟁의기간을 연차휴가 산정에서 어떻게 취급할 것인지에 관한 주장은 크게 3가지로 구분할 수 있다.²⁹⁾

첫째로, 헌법상의 단체행동권의 보장 법리를 중시하여 쟁의기간을 소정 근로일수에도 포함되되, 출근한 것으로 보는 견해(출근간주설)가 있다. 이 견해는 연차휴가권의 발생 또는 출근일수에 일정한 근속기간 또는 출근을 요구하는 것은 근로자의 귀책사유가 일정한 한도를 넘지 않아야 한다는 것을 의미하는데, 정당한 쟁의행위에서는 근로자의 귀책사유가 없을 뿐만 아니라, 단체행동에 관한 불이익취급을 금지하고 있는 헌법의 취지를 고려할 때 출근한 것으로 보아야 함을 전제로 하고 있다. 그러나 법조항에 규정된 전문적 또는 일상적 용어가 가지는 의미적 표현에 충실해야 한다는 문언적 해석기준에 따르면, 출근은 근로제공을 위한 사업장에 도착하여 사용자의 지시를 받을 수 있는 상태를 의미하지만 근로제공을 위해 사업장에 도착한 것이 아니라면 비록 사업장에 나와도 이를 출근으로 해석할 수는 없다. 또한 휴일의 규정을 고려할 때 휴가규정은 일반적으로 출근하지 않는 경우 근로자에게 불이익하게 처리해야 하지만, 근로자에게 귀책사유가 없는 업무상 질병 등의 경우에는 출근한 것으로 간주하여 불이익이 발생하지 않도록 규정하고 있으므로, 이러한 간주규정이 없는 쟁의행위기간을 출근으로 인정할 수 없을 것으로 보인다. 근기법 제60조 제1항 내지

29) 임종률, 앞의 책, 440면의 학설들을 기준으로 함.

제7항의 체계와 내용을 고려할 때, 법률에 명문으로 연차휴가를 취득하기 위해 출근으로 간주되는 것으로 규정되지 않는 경우는, 결근으로 보아야 하는지는 별론으로 하더라도, 최소한 출근으로서는 파악해서는 안된다고 해석할 수 있기 때문이다.

둘째로, 앞서 제3장에서 살펴본 견해인, 연차휴가의 산정은 근로(제공)의무를 전제로 하기 때문에, 쟁의행위기간은 소정근로일 자체에서 제외된다고 보는 견해(소정근로일제외설)가 있다. 이 입장은 연차휴가 산정을 근로(제공)의무라는 통일적인 기준으로 해석하여 법적 안정성을 도모함과 동시에 산정의 구체화를 시킬 수 있다는 장점이 있다. 그 뿐만 아니라 “근로자의 정당한 권리 행사”에 대한 “불이익”을 방지한다는 헌법적 요청에도 충실하다. 연차휴가 산정에 관한 판결은 아니지만, 대법원은 임금 산정시 기간에 관한 판결에서 “근로자의 정당한 권리행사 또는 근로자에게 책임을 돌리기에 적절하지 않은 사유로 근로자가 평균임금 산정에서 불이익을 입지 않도록 특별히 배려한 구 근로기준법 시행령(2003. 12. 11. 대통령령 제18158호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항의 취지 및 성격을 고려할 때,³⁰⁾ 그 제6호 ‘노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제6호의 규정에 의

³⁰⁾ 대법원 2009.5.28. 선고 2006다17287 판결. 이 판결은 근로기준법시행령 제2조(대통령령 제18158호(2003.12.11)로 개정되기 이전의 것)의 쟁의행위의 개념을 해석한 것이다. 동 시행령은 다음과 같이 규정되어 있는데, 이는 연차휴가의 경우와 유사하면서도 쟁의행위기간을 명시적으로 다루고 있다는 점에서 차이가 있다.

제2조 (평균임금의 계산에서 제외되는 기간 및 임금)

① 법 제19조의 규정에 의한 평균임금 산정기간 중에 다음 각호의 1에 해당하는 기간이 있는 경우에는 그 기간과 그 기간 중에 지불된 임금은 평균임금 산정기준이 되는 기간과 임금의 총액에서 각각 공제한다.

1. 법 제35조제5호의 규정에 의한 수습사용중의 기간
2. 법 제45조의 규정에 의한 사용자의 귀책사유로 인하여 휴업한 기간
3. 법 제72조의 규정에 의한 산전후휴가기간
4. 법 제81조의 규정에 의한 업무수행으로 인한 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간
5. 남녀고용평등법 제19조의 규정에 의한 육아휴직기간
6. 노동조합및노동관계조정법 제2조제6호의 규정에 의한 쟁의행위기간
7. 병역법·향토예비군설치법 또는 민방위기본법에 의한 의무이행을 위하여 휴

한 쟁의행위 기간이란 헌법과 노동조합 및 노동관계조정법에 의하여 보장되는 적법한 쟁의행위로서의 주체, 목적, 절차, 수단과 방법에 관한 요건을 충족한 쟁의행위 기간만을 의미한다. 만약, 이와 달리 위와 같은 요건을 충족하지 못하는 위법한 쟁의행위 기간까지 제한 없이 제6호에 포함되는 것으로 해석하게 되면, 결과적으로 제6호의 적용 범위 또는 한계를 가늠할 수 없게 되어 평균임금 산정 방법에 관한 원칙 자체가 무의미하게 되는 상황에 이르게 되는바, 이는 평균임금 산정에 관한 원칙과 근로자 이익 보호 정신을 조화시키려는 구 근로기준법 시행령 제2조 제1항의 취지 및 성격이나 근로자의 권리행사 보장이 필요하거나 근로자에게 책임을 돌리기에 적절하지 않은 경우만을 내용으로 삼고 있는 위 조항의 다른 기간들과 들어맞지 않기 때문이다”라고 보아서 정당한 쟁의행위는 “근로자의 정당한 권리 행사”이며, 이로 인한 “불이익”이 근기법상 기간 산정에서 고려되어야 한다는 입장을 보이고 있다. 그러나 ① 평균임금산정이 법적 근거가 명확한 것과 달리 쟁의기간에 관해서는 근기법(동법 시행령과 시행규칙 포함)에 별도의 규정이 없다는 점과 ② 정당한 쟁의기간만을 소정근로일에서 제외된다고 보면, 쟁의행위의 정당성은 사후 법률적 검토를 통해서 판단되는 것이므로, 연차휴가 산정 기준기간(1년)이 경과한 상태에서 쟁의행위의 정당성이 판단되지 않았을 때, 실질적인 연차휴가 산정이 힘들다는 점³¹⁾ 및 ③ 소정근로일제외설의 경우에는 연차휴가의 보상적 성격을 반영하지

직하거나 근로하지 못한 기간. 다만, 그 기간 중 임금을 지급받은 경우에는 그러하지 아니하다.

8. 업무외 부상·질병 기타의 사유로 인하여 사용자의 승인을 얻어 휴업한 기간
② 법 제19조제1항의 규정에 의한 임금의 총액에는 임시로 지불된 임금 및 수당과 통화외의 것으로 지불된 임금은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 노동부장관이 정하는 것에 대하여는 그러하지 아니하다.

- 31) 쟁의행위의 정당성에 따라 연차휴가의 발생요건이 달라진다면, 일본의 노기법 제115조와 같이 시효에 관한 규정(이 법률에 의한 임금(퇴직수당을 제외), 재해보상 기타 청구권은 2년간, 이 법률의 규정에 의한 퇴직수당의 청구권은 5년간 행사되지 않는 경우에는, 시효에 의하여 소멸하다)이 없는 한 연차휴가 보상금의 문제로 귀결될 것이다. 이러한 해결법은 연차휴가를 실제 휴가로 부여하도록 촉진하는 근기법 제61조(연차유급휴가의 사용 촉진)의 취지에 부합되지 않는다.

않는다는 점에서 문제가 있다고 볼 수 있다.

셋째로, 쟁의기간을 소정근로일수에서 제외하여 “8월의 출근” 요건을 판단하되, 구체적 휴가일수는 연간 총 소정근로일수에 대한 나머지 소정근로일수의 비율을 곱하여 산정하는 방식(비례삭감설)이다. 쟁의기간동안 현실적으로 출근한 경우와의 형평성을 근거로 쟁의기간의 길이에 비례하여 휴가일수를 삭감하여야 한다고 보며, 이는 연차휴가제도의 보상적 성격을 강조한 입장이라고 볼 수 있다. 비례삭감설은 연차휴가의 발생요건은 소정근로일제외설과 동일하게 판단하면서도, 실제 휴가는 쟁의행위기간을 고려한다는 점에 특색이 있다. 비례삭감설은 쟁의기간이 1년에 걸치는 경우 산정이 불가능하다는 등 소정근로일제외설의 문제점을 그대로 갖고 있을 뿐만 아니라 비례삭감의 법률적 근거가 없다는 점에서 비판받고 있다.

이상의 학설들을 구체적으로 적용해 보면, 휴일이 114일로 소정근로일이 251일이고, 파업참가기간이 90일, 개인 사정으로 결근한 날이 7일인 경우, 근속연수를 고려하지 않았을 때의 각 입장에 따른 출근율 및 연차휴가일수는 다음과 같이 산정된다.

<표 3> 각 방안의 비교

	출근율	연차휴가일수
소정근로일제외설	$0.96 = (251 - 90 - 7) \div (251 - 90)$	15일
비례삭감설	$0.96 = (251 - 90 - 7) \div (251 - 90)$	약 9.5일 $= 15 \times \{(251 - 90 - 7) \div 251\}$
출근간주설	$0.97 = (251 - 7) \div 251$	15일

2. 법적 흠결과 보완방법

(1) 문제점

근기법 제60조에서 정한 요건에 해당하여 연차휴가권이 발생하면 이것은 보장적 성격으로 파악해야 하지만, 발생요건에 해당하기 위한 구성요소

의 사실인 소정근로일수와 출근일 그 자체에 대해서는 보장적 성격으로 해석하기 어렵다. 한편 쟁의행위는 헌법상 보장하는 권리이므로 헌법상 권리를 행사하는 근로자에게 불이익한 해석방법은 법령에 근거하거나 법리상 명백한 경우로 제한되어야 할 것이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 근기법 및 동법 시행령과 시행규칙에서 연차휴가권의 보상적 성격의 한계를 명확하게 하기 위한 근기법 시행령 제2조(평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금) 제6호와 같은 규정이 연차휴가 산정에도 필요하다. 그러나 이러한 규정이 없는 한 연차휴가제도의 법적 성격으로 파악될 수 있는 “보상적 성격”이 헌법상 권리인 쟁의기간과 어떠한 관련성이 있는지 명확하지 않으며 양자에 대한 균형 있는 해석이 필요하다. 한 측면만을 강조하게 되면 근기법이 예상하지 못한 것으로 인해 이익을 보거나 상당한 불이익을 입게 되므로, 이것은 바람직한 입법태도 또는 해석이 될 수 없다. 이를 보완하는 방법은 현행법을 전제로 해석에 의하거나 입법을 통한 것을 생각할 수 있는데, 여기서는 전자에 관해 검토한다.

(2) 법적 흠결과 해석상 보완

과업참가기간과 연차휴가의 발생요건에 관해 현행 근기법 제60조의 규정은 '명시적 법적 흠결'은 아닐지라도 최소한 '은폐된 법적 흠결'로 파악될 가능성이 높다. 법적 흠결은 해석론에 의해 유추해석 및 목적론적 축소 등의 해석론에 의해서 보완되지만, 보편적인 법원리를 통해 보완되기도 한다. 보편적인 법원리는 법의 일반원칙, 법질서의 정신, 자연법과 사물의 본성, 정당한 목적을 위한 합법적 수단 등이 있다. 물론, 이러한 법 원리들이 어디에 근거하고 그들 사이의 선호관계는 어떤 것인지를 일률적으로 쉽게 대답될 수 있는 것은 아니다. 그러나 '권리와 책임'에 기초한 합리성과 법적 안정성과 같이 보편적으로 타당한 법원칙은 법적 흠결을 보완하는 중요한 원칙과 기준이 된다.³²⁾ 이러한 점을 고려할 때 양 제도의 취지를 고

32) 김영환, 법철학의 근본문제, 홍문사, 2006, 272면 이하 참고.

려하여 다음과 같은 점이 반영된 해석이 필요할 것이다.

첫째, 근기법상 연차휴가는 보장적 또는 보상적 성격인지에 관한 논의가 있는 바, 전자라고 하면 법적 근거 없이 근로조건을 삭감 또는 감축해서는 아니된다. 그러나 연차휴가제도의 취지와 발생요건에 관한 문언적 해석의 미 및 다른 제도와의 관계에서 볼 때, 보장적 제도로 단정하기는 힘들며 일정부분 보상적 성격이 존재하는 것으로 보아야 한다.

둘째, 근로시간에 관한 근기법의 내용이 변경되었다는 점이 휴가요건에 관한 해석에 직접적으로 영향을 미친다고 단정할 수는 없지만, 간접적으로 미치는 영향을 부정할 수는 없다. 구 근기법상 월차와 연차 휴가제도를 변경하게 된 것에는 여러 가지 이유가 있지만, 주로 1주간 44시간이던 소정 근로시간을 주40시간으로 변경함에 따라 휴가의 형태와 내용에 관한 취득 요건을 변경한 것으로 파악된다. 주당 4시간을 단축하게 되면, 1개월에 약 2일, 1년에 약 24일의 소정근로일수가 줄어들게 되어 근로자에게 주어지는 중요한 근로조건인 휴가의 형태와 정도를 변경할 필요가 생겼기 때문이다. 소정근로일수가 감소함에 따라 출근을 해야 한다는 의미에 가해지는 의미와 폭은 강해질 수 있다. 1년에 소정근로일수가 약 274일이고 약 100일이 근로제공의무가 없는 구 근기법의 입법형태와, 1년에 소정근로일수가 약 250일이고 약 124일이 근로제공의무가 없는 현행 근기법상 휴가제도로 변경은, 법적 흠결을 보완하는 해석에서는 고려될 수 있는 사항이다.

셋째, 자발적 휴직 또는 결근한 근로자와 형평성이다. 헌법상 보장된 노동3권의 중요한 내용인 파업참가자에게 연차휴가 등에서 불이익을 줄 수는 없다. 그렇다고 이들을 다른 근로자보다 유리하게 보호해서도 아니된다. 그 내용에는 근로제공을 하지 않는 경우 무노동·무임금의 원칙, 근기법에서 규정하고 있는 근로조건의 부여가 그 대상 등이 될 것이다. 개별 사업장에서 휴직과 연차휴가 등에 관해 특별한 규정이 없다면 근기법상 요구되는 내용이 적용되게 된다. 경영상 휴업 등으로 인한 휴직은 근로자에게 책임사유가 없어 소정근로일수에서 제외되고 결근으로 파악되지 않으므로 근기법에 규정된 연차휴가에서 해당 근로자에게 불이익은 없다. 그러나 특

정 근로자가 개인적인 사정으로 자발적으로 휴직을 원하여 사용자가 이를 인정한 경우라도, 연차휴가에서 요구되는 출근으로 파악할 수는 없다. 이와 비교할 때 쟁의행위에 대한 참가권은 자신들에게 유리한 근로조건 또는 기타 근로자대우에 관한 권리를 쟁취하기 위해 헌법과 노조법에 보장된 권리이지만, 근로자들이 이를 행사함으로써 인하여 근로를 제공하지 않았다면, 그들과 쟁의행위에 참가하지 않은 근로자들과 비교하여 유리 또는 불리하게 대우해서도 아니되고, 근로조건에서 가능한 균등하게 보호되도록 해석해야 한다. 이것은 법적 흠결을 보완하는 합리성의 중요한 내용이 될 수 있다.

(3) 비례삭감방안의 검토

행정해석³³⁾은 파업참가일을 소정근로일수에서 제외하되, 휴가일수는 연간 총 소정근로일수에 대한 나머지 소정근로일수 비율을 곱하여 산정해야 한다고 본다. 현실적인 출근을 한 근로자와의 형평성을 감안하여 근로자의 휴가일수와 비례를 맞추어야 한다는 것이다. 이것은 명확한 법적 근거 없이 형평성만을 이유로 비율적으로 연차휴가를 인정하는 것이 되어 그 규범적 타당성에 관해 비판이 제기될 수 있다. 그러나 연차휴가제도의 법적 성격 중 “보상적 성격”을 감안한다면, 기본적으로 쟁의행위 기간이 소정근로일에서 제외된다는 소정근로일제외설을 기본으로 하고, 연차휴가의 보상적 성격을 통해 비례적으로 구체적 휴가일수를 부여한다고 할 때 양 제도의 취지에 일정부분 부합한다고 볼 수 있다. 비례삭감설의 입장에서는 쟁의기간이 길어질수록 연차휴가일수가 줄어드는 것은 근로에 대한 보상의 성격이 감소하기 때문이라고 볼 수 있다. 그러나 쟁의행위의 참가로 인하

³³⁾ 노동부 2007. 10. 25 임금근로시간정책팀-3228(연차유급휴가 부여시 소정근로일수 및 출근여부 판단기준에서 정직 등에 관한 점은 변경되었지만, 쟁의행위와 연차휴가의 산정기준에 관해 비례적 계산을 한 내용은 변경되지 않았다. 쟁의행위와 연차휴가에 관한 이러한 행정해석은, 일본에서 나온 釧路交通事件에 대한 札幌高裁의 판결을 참조한 것으로 파악된다.

여 일정한 불이익이 발생하는 것은 사실인 바, 이러한 불이익이 헌법상 단체행동권 보장의 취지를 침해할 것인지에 관해서는 별도의 검토가 필요하다. 특히 장기간 쟁의행위에 참가한 근로자는 비참가 근로자에 비하여 불이익을 받을 수 있다는 점이 문제될 수 있다. 예컨대 휴일이 114일로 소정근로일이 251일이고, 개인 사정으로 결근한 날이 7일인 경우, 근속연수를 고려하지 않았을 때 파업일수를 각 30일, 60일, 90일, 120일, 150일로 산정하였을 때 휴가일수는 다음과 같다.

<표 4> 쟁의행위기간에 따른 연차휴가(비례삭감설)

쟁의기간	출근율	연차휴가일수
30일	$0.97=(251-30-7)\div(251-30)$	$15\times(221/251)=\text{약 } 13\text{일}$
60일	$0.96=(251-60-7)\div(251-60)$	$15\times(191/251)=\text{약 } 11.5\text{일}$
90일	$0.95=(251-90-7)\div(251-90)$	$15\times(161/251)=\text{약 } 9.5\text{일}$
120일	$0.95=(251-120-7)\div(251-120)$	$15\times(131/251)=\text{약 } 8\text{일}$
150일	$0.93=(251-150-7)\div(251-150)$	$15\times(101/251)=\text{약 } 6\text{일}$

구체적 사례에 따라 차이가 있겠지만, 비례삭감설은 쟁의행위가 1개월 이내의 단기의 경우에는 실제 휴가일수의 차이는 크지 않다. 그러나 쟁의기간이 길어지면 길어질수록 연차휴가일수가 줄어들게 되어 연차휴가의 근로보상적 성격을 더욱 반영하게 된다. 이러한 해석은 동법 제60조가 예정하고 있는 소정근로일과 출근에 관한 문언적 의미, 다른 근로조건 제도와 의 체계, 연차휴가제도를 현행 근기법처럼 개정한 입법취지를 모두 고려한 다 하더라도, 쟁의기간에 대한 실질적 불이익으로 볼 소지가 있다.

그러나 현행법의 내용에 일정한 법적 흠결이 있다고 한다면, 입법적 보완을 하기 전까지는 연차휴가의 보상적 취지를 반영함과 동시에 발생요건에서 불이익을 배제하고 있는 소정근로일제외설의 기본 입장을 반영한 절충설의 입장을 선택하여 근로자와 사용자 사이에 제기된 노동분쟁을 해결

하는 것은 양 제도의 취지를 모두 반영하는 것으로 볼 여지가 있으므로, 비례삭감설은 이러한 한도 내에서 그 의미를 찾을 수 있을 것이다.

VI. 결론을 대신하며

근기법에서 규정하고 있는 연차휴가의 요건을 해석하기 위한 출발점은 동 제도의 법적 성격을 파악하는 것이다. 앞의 비교법적 검토를 통해 살펴본 바와 같이 영국과 독일에서는 연차휴가를 보장적 성격으로, 일본과 우리나라에서는 보상적 성격에 가까운 것으로 파악된다. 그러나 동 제도가 보상적 성격만을 가진다고 볼 수는 없으며, 보장적 성격이 혼재하여 있다. 그러므로 우리나라의 근기법상 연차휴가제도를 보장적 또는 보상적 성격인지에 관한 논의를 통해서 연차휴가의 요건을 도출하려는 방법론은 완전한 결론을 내릴 수 없다.

그런데, 연차휴가를 보장적으로 해석하지 않는 한 연차휴가권이 모든 근로자에게 동일하게 보장되는 근로조건으로 파악하기는 힘들다. 근기법 역시 일단 발생한 연차휴가권에 대해서 보장적으로 파악하는 것과는 별도로, 발생요건에 대해서는 80%의 출근이라고 규정하고 있으므로 이 요건을 충족하는 한도에서만 발생하는 것은 당연하다. 근기법 제60조는 해석의 기준인 소정근로일수가 근로관계에서 발생하는 추상적인 근로제공의무의 존재를 전제로 함에 반하여 법문상의 출근은 근로자가 근로를 제공하기 위한 구체적인 이행상태를 의미하기 때문에 해석상 문제가 발생한다. 이러한 영역에서는 법적 해석론이 우선시되어야 하며, 사용자에게 취업규칙으로 근기법 제60조의 요건들을 규정할 권한은 인정될 수 없다. 그러므로 구체적인 사안들에서 사용자가 임의로 정한 근로의무 유무 역시 해석을 통해 근기법의 규정에 위반되지 않는지 검토되어야 한다.

연차휴가권의 발생요건에 관한 학설 중 소정근로일제외설은 연차휴가 산정법을 근로(제공)의무라는 통일적인 기준으로 해석하여 법적 안정성을

도모함과 동시에 산정의 구체화를 시킬 수 있다는 장점이 있다. 그러나 연차휴가의 보상적 성격을 반영하지 않고 있으므로, 연차휴가에 관한 근기법의 취지에 부합되지 않는다는 비판이 있을 수 있다. 한편 비례삭감설은 발생요건을 소정근로일제외설과 같이 근로(제공)의무라는 통일적인 기준으로 해석함과 동시에 구체적인 휴가일수는 연차휴가의 보상적 성격을 반영하여 비례적으로 부여함으로서 보장적 성격과 보상적 성격을 모두 반영하고 있는 연차휴가의 취지에 부합된다.

그렇지만 비례삭감설은 기간이 길어질수록 보상적 성격이 짙어지게 되고, 이는 장기의 쟁의행위와 같이 헌법상 보장된 권리행사의 경우에 더욱 문제될 수 있다. 또한 비례삭감설은 현행법의 취지를 반영함과 동시에 구체적 타당성을 강조하여 근로자와 사용자 사이에 발생한 분쟁해결을 위한 것이지, 법 이론상 명확하게 도출할 수 있는 것은 아니다. 쟁의행위의 경우 쟁의기간과 소정근로일수, 출근의 관계 등에서 문제점은 여전히 남게 되므로, 입법적으로 해결하는 것이 바람직하다.³⁴⁾ 해석적인 통일성을 기하기 위해서는 근기법 시행령 제2조(평균임금의 계산에서 제외되는 기간과 임금) 제6호(「노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제6호에 따른 쟁의행위)와 같은 규정이 연차휴가 산정에도 필요하겠지만, 보다 근본적인 문제점을 해결하기 위해서는 연차휴가의 보상적 성격에 대한 타당성이 검토되어야 할 것이다.

연차휴가에 관한 우리의 입법구조는 국제기준과는 달리 본래적 의미에서의 여가를 보장한 보장적 성격으로만 보기는 힘든데, 이는 우리 노사관계법에 영향을 미친 일본의 입법을 기반하고 있다는 입법모델의 문제와

34) 근기법상 연차휴가제도는, 첫째, 보상적 휴일과 보장적 성격 및 보상적 성격이 동시에 존재하는 연차휴가에 대한 통일적 규정이 결여되고 있고, 둘째, 법에 직접적으로 규정하지 않은 상태에서 시행령의 규정마저 없이 소정근로일을 기준으로 하고 있거나 시행령에 규정이 있어도 법의 위임규정이 없으며, 셋째, 소정근로시간과는 달리 소정근로일에 대해서는 법에 정의 규정이 없다는 문제점이 있으므로 입법론적인 보완이 필요하다는 견해가 있다. 이에 관해서는 하갑래, 「근로기준법」 (21판), (주)중앙경제, 2009, 365면 참조.

더불어 지금까지 우리의 노사현실에서 연차휴가의 사용이 저조한 대신 연차휴가수당을 통한 임금보전적 성격이 높았기 때문으로 보인다. 그러나 현행 근기법 제61조에서 연차휴가의 사용촉진을 규정하면서 임금보전적 성격을 부정하려고 한다는 점과 현실적으로 연차유급휴가의 임금보전적 성격이 약해지고 있으며 여가 활용으로 수단이 되고 있다는 점을 고려한다면, 현재의 보상적 성격이 짙은 입법구조는 해석론적인 문제점을 발생시킬 뿐만 아니라 연차휴가의 본래의 성격과도 부합되지 않는다. 이에 대한 향후 입법론적인 재검토가 필요할 것으로 보인다.

(투고일 2010.2.28; 심사일 2010.3.8; 게재확정일: 2010.3.20)

주제어 : 연차휴가의 법적 성질, 쟁의행위와 연차휴가, 취업규칙의 효력

<Abstract>

The Legal Characteristic and Problem of Annual Leave

Park, Su-Keun^{*}

Kim, Keun-Ju^{**}

Annual leave is paid time off work granted by employers to employees to be used for whatever the employee wishes. To contribute to healthful and cultural life, annual leave with paid must guarantee employees. Most countries around the world have labour laws that mandate employers give a certain number of paid time-off days per year to workers.

The Labour Standards Act in Korea provide required condition of the annual leave entitlement except continuous employment. This legislative system is very unique compared with international labour standard and other countries. In addition, annual leave in the Labour Standards Act provide that it should be gradually increased in proportion to the number of years of continuous service. This is clinical significance because annual leave in Korea is not in accordance with other countries in point of view of the legal characteristic.

The aim of this study is to look into the legal nature of annual leave in our legislation and to find resonable analytical method based on it. To research this work, I began to study comparative one and examined

^{*} Professor, Hanyang University Law School

^{**} PH.D. Candidate in Law, Hanyang University

the parallel and difference between them. Through this work, I find that annual leave system in Korea have two main legal characteristic conflicting with each other. That is guaranteed aspect to employee and contributed one to employer. Both of them are important to judge the required condition of the annual leave entitlement. However, this judicial analysis is not desirable considered because annual leave is naturally a benefit for the employees, and, in case of strike, that the Constitution bans disadvantage by the reason of right to strike. Reciprocally also, annual leave in the Labour Standards Act is part of the Constitution, and both are not different kinds, but different part of law. In conclusion, the core legal characteristic of annual leave is understood in respect of right of employees.

Key words: the right to annual leave, the relationship between right to strike and contract of employment, Calculating the annual leave entitlement